

1502118-69.2021.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/03/2022

... de fachada que, na verdade, era ponto de tráfico de entorpecentes), e os péssimos antecedentes criminais, circunstâncias concretas obstativas da aplicação da referida minorante. 8. Ordem denegada." (STF HC 111.666/MG Rel. Min. Luiz Fux j. 08.05.12 DJU 23.05.12).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

2ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Maua - SP - cep 09371-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502118-69.2021.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502118-69.2021.8.26.0540

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO DA SILVA MORAIS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

LEANDRO DA SILVA MORAIS foi denunciado por incursão no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que no dia 15 de setembro de 2021, por volta das 15h45min, na rua Lourival Portal da Silva, 106, Jardim Zaira, nesta cidade e comarca de Mauá, o denunciado trazia consigo e expunha à venda, para entrega a consumo de terceiros, as substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, descritas no auto de exibição e apreensão (fls. 9-10) e laudo de constatação (fls. 14-7), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação.

Testemunhas arroladas pelas partes devidamente inquiridas. Por fim, o réu foi interrogado.

Em memoriais finais, o Ministério Público requer a procedência da ação penal, enquanto a Defesa requer a nulidade da instrução por inobservância ao procedimento relativo ao acordo de não persecução penal. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória ou, ao menos, a aplicação da pena nos patamares mínimos, com o reconhecimento da confissão e do tráfico privilegiado, a fixação de regime penitenciário inicial brando, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

Malgrado o esforço argumentativo do douto Defensor Público, a preliminar levantada não se sustenta. A questão atinente ao acordo de não persecução penal já foi devidamente afastada no momento oportuno, notadamente pela falta de requisito objetivo (fls.136-42).

No mérito, a acusação procede.

A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 04-6), auto de exibição e apreensão (fls. 9-10), laudo de constatação (fls. 14-7), laudo definitivo (fls. 167-71 e 202-4) e prova oral colhida.

Comprovou-se a autoria.

Interrogado, em solo policial, o réu permaneceu em silêncio (fls. 07-8).
Em juízo, manifestou-se. Negou que estivesse na posse de crack (mídia digital).

O policial civil Severino, na fase administrativa (fl.02), historiou que: (sic) "estava em diligência, visando coibir o tráfico de entorpecente, em companhia do policial Douglas. Que se dirigiram ao local dos fatos, o qual já conhecido ponto de venda de entorpecentes, e estacionaram a viatura caracterizada da Polícia Civil. O policial Douglas permaneceu na viatura e o depoente foi averiguar uma rua sem saída próxima. O depoente entrou pela rua sem saída e se deparou com um indivíduo em atitude suspeita, o qual ficou muito agitado e nervoso com a presença do depoente. O indivíduo foi abordado pelo depoente e, na revista pessoal, o depoente constatou que o indivíduo estava com duas pochetes por baixo das vestes. Ao abrir as pochetes o depoente constatou que elas continham diversas substâncias aparentando serem entorpecentes e uma pequena quantia em dinheiro. No local o indivíduo relatou que estava praticando o tráfico naquele lugar há cerca de quatro dias, ganhando o percentual de 20 por cento do valor dos entorpecentes. O indivíduo relatou também que os entorpecentes teriam sido passados para ele por um indivíduo que teria feito as vendas durante a noite, sendo que não sabe informar o nome ou qualquer qualificação dessa pessoa. O depoente acionou o policial Douglas por telefone, sendo que este veio dar apoio ao depoente e ajudou na condução do indivíduo, posteriormente identificado como Leandro da Silva Moraes, sendo que o policial Douglas não presenciou a abordagem".

Em juízo, disse que o local é conhecido por outras prisões pela prática de tráfico de drogas. O policial Douglas ficou no começo da viela, era uma rua sem saída. A poucos metros viu o réu em atitude suspeita, que ficou muito nervoso e foi abordado. O acusado estava na posse de duas pochetes, dentro de suas vestes, com drogas, aproximadamente, 70 invólucros de maconha, cocaína, crack e uma quantia em dinheiro. O réu disse que trabalhava no tráfico há quatro dias e ganharia 20% do valor das vendas. Acrescentou que o réu foi detido 15 dias após os presentes fatos,

no mesmo local, pela prática de tráfico de entorpecentes (mídia digital).

A prova por meio de depoimento de policiais não é desvaliosa, quanto ao actum a que corresponda, pela só condição profissional das testemunhas. Ao revés, estar-se-ia diante de uma acepção processual de pessoas com apoio em predicado genérico. A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que não é causa simpliciter de menor credibilidade a circunstância de uma testemunha ser policial. Nessa linha:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07).

No mais, descabida a alegação da Defesa quanto à ilegalidade na busca pessoal, uma vez que o policial que realizou a abordagem afirmou que encontrou o réu, em local conhecido pela prática de tráfico de drogas, em atitude suspeita na viela, ficou muito nervoso com a presença do policial, demonstradas, assim, fundadas razões para a busca pessoal do réu.

A quantidade de droga encontrada e as demais circunstâncias da apreensão, tais como a variedade e a forma em que era transportada, além do dinheiro encontrado com o acusado, trazem elementos suficientes de que o réu tinha as drogas para entrega a terceiros.

Dessa forma, entendo que o delito está fartamente comprovado.

Passo à fixação da pena.

Atendendo aos ditames do art. 42 da Lei 11.343/06 e do art. 59 do Código Penal, a pena deve ser fixada no mínimo legal, qual seja, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, justifica-se a não incidência da atenuante da confissão, não espontânea e sequer integral, em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal. Isso porque a confissão de quem foi preso em flagrante na posse de entorpecentes, não tem o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos. Não fosse suficiente, o presente decísum sequer referiu-se ao interrogatório do réu, portanto, sem infringência à Súmula 545 do STJ.

Sobre a necessidade da espontaneidade da confissão, decota-se trecho do voto do v. acórdão proferido pelo eminente Desembargador Ricardo Dip, no julgamento da Apelação Ordinária 1.390.581-8:

"Em acréscimo, confissão do acusado, houve. Espontânea, contudo, não; a que houve, tem caráter de provocada.

É válida –recruto de votos precedentes–, é válida, repito, ainda após a controvertida Reforma do Código Penal em 1984, esta lição de Roberto Lyra:

'A espontaneidade da confissão não diz respeito, é claro, à sua prestação, em que seria redundante a referência...' (Comentários ao Código Penal, ed. Forense, Rio de Janeiro, 1958, vol. 2, n. 64).

Não fosse assim, sobeja seria a lei, porque, como disse Fragoso, 'se o agente confessa sob pressão policial, fato, aliás, comum, nenhuma atenuante será aplicável' (Lições de Direito Penal, ed. Forense. Rio de Janeiro, 1994, Parte

Geral, n. 345).

Na mesma linha, disse Mirabete: 'Não basta a confissão para a configuração da atenuante; é necessário que o agente, arrependido, procure a autoridade para a confissão, já que a lei não fala em ato voluntário, mas em confissão espontânea' (Manual de Direito Penal, ed. Atlas, São Paulo, 1997, vol. 1, 7.5.6).

Diz José Antonio Paganella Boschi, comentando o disposto na alínea d, inc. III, art. 65, CP: 'Foge ao sentido do texto, portanto, reconhecer a atenuante quando o agente é preso em flagrante e não tem como negar as evidências em torno da autoria ou imputar a responsabilidade pelo fato a terceiro. Inconfundíveis confissão espontânea e confissão voluntária' (Das Penas e Seus Critérios de Aplicação, ed. Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2002, p. 273).

A espontaneidade da confissão –prevista em lei como qualificação necessária do ato confessorio para atuar como causa de atenuação penal– distingue-se da mera voluntariedade da confissão. Não se trata aí do espontâneo como o que procede de um princípio interno juxta naturam agentis, sine deliberatione (Marcelino Zalba), mas do que (disse Cathrein) procedit a principio interno –ou seja, sem provocação exterior." (TACRIM-SP –11a Câmara)

Manifestou-se, também, o Supremo Tribunal Federal quanto à incompatibilidade da atenuante da confissão espontânea com a situação de flagrância:

“CONFISSÃO ESPONTÂNEA ATENUANTE. Em se tratando de situação concreta em que ocorrida a prisão em flagrante, em razão do transporte de vultuosa quantidade de droga, descabe cogitar da atenuante da confissão espontânea, no que esta última tem como objetivo colaborar com o Judiciário na elucidação da verdade real”. (HC 101.861/MS, rel. Min. Marco Aurélio, 1ª T., j. em 13.04.2011)

No mesmo julgamento, manifestou-se o Min. Luiz Fux: “Eu também entendo que confissão espontânea e flagrante é contradictio in terminis, não dá para conviver; ou confessa voluntariamente ou é preso em flagrante. Não fez favor nenhum à Justiça”.

Registre-se que não deve incidir, no caso concreto, a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Restou demonstrado que o réu foi preso em flagrante em local notoriamente conhecido como ponto de tráfico com significativa quantidade e variedade de entorpecentes, sabidamente dominado por facções criminosas, portanto, sem espaço para "iniciantes" e não houve comprovação idônea do exercício de atividade lícita, a indicar um acentuado envolvimento no comércio de drogas, ou seja, a não ocasionalidade da conduta. Acresce-se que o policial informou que o réu foi detido 15 dias após os presentes fatos, no mesmo local, pela prática de tráfico de entorpecentes (cert fl.166). Nessa direção:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, I, DA LEI 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. AFASTAMENTO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. ANÁLISE DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA OU DE SER INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADES NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM DENEGADA. 1. A causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da lei 11.343/06 está condicionada ao preenchimento, cumulativo, dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes e agente que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. [...] 3. A conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza do entorpecente, os apetrechos utilizados e as circunstâncias em que a droga foi apreendida podem constituir o amparo probatório para o magistrado reconhecer a dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes: RHC 94.806/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/04/2010; HC 116.541/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes,

Segunda Turma, DJe de 6/6/2013; HC 98.366/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 5/2/2010. [...] (STF HC 121.057/SP Rel. Min. Luiz Fux j. 25.02.14 DJU 18.03.14).

"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA, MAUS ANTECEDENTES E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. PRESUNÇÃO HOMINIS. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS. APTIDÃO PARA LASTREAR DECRETO CONDENATÓRIO. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. DESCABIMENTO NA VIA ELEITA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA APTA A AFASTAR A MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06, ANTE A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ORDEM DENEGADA. 1. O §4º do artigo 33 da Lei de Entorpecentes dispõe a respeito da causa de diminuição da pena nas frações de 1/6 a 2/3 e arrola os requisitos necessários para tanto: primariedade, bons antecedentes, não dedicação à atividades criminosas e não à organização criminosa. 2. Consectariamente, ainda que se tratasse de presunção de que o paciente é dedicado à atividade criminosa, esse elemento probatório seria passível de ser utilizado mercê de, como visto, haver elementos fáticos conducentes a conclusão de que o paciente era dado à atividade delituosa. 3. O princípio processual penal do favor rei não ilide a possibilidade de utilização de presunções 'hominis' ou 'facti', pelo juiz, para decidir sobre a procedência do 'ius puniendi', máxime porque o Código de Processo Penal prevê expressamente a prova indiciária, definindo-a no art. 239 como 'a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias'. Doutrina (LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale Penale. v. II. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1961. p. 161-162). Precedente (HC 96062, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-02 PP-00336). 4. Deveras, o julgador pode, mediante um fato devidamente provado que não constitui elemento do tipo penal, utilizando raciocínio engendrado com supedâneo nas suas experiências empíricas, concluir pela ocorrência de circunstância relevante para a qualificação penal da conduta. 5. A criminalidade dedicada ao tráfico de drogas organiza-se em sistema altamente complexo, motivo pelo qual a exigência de prova direta da dedicação a esse tipo de atividade, além de violar o sistema do livre convencimento motivado previsto no art. 155 do CPP e no art. 93, IX, da Carta Magna, praticamente impossibilita a efetividade da repressão a essa espécie delitiva. 6. O juízo de origem procedeu a atividade intelectual irrepreensível, porquanto a apreensão de grande quantidade de droga é fato que permite concluir, mediante raciocínio dedutivo, pela dedicação do agente a atividades delitivas, sendo certo que, além disso, outras circunstâncias motivaram o afastamento da minorante. 7. In casu, o Juízo de origem ponderou a quantidade e a variedade das drogas apreendidas (1,82g de cocaína pura, 8,35g de crack e 20,18g de maconha), destacando a forma como estavam acondicionadas, o local em que o paciente foi preso em flagrante (bar de fachada que, na verdade, era ponto de tráfico de entorpecentes), e os péssimos antecedentes criminais, circunstâncias concretas obstativas da aplicação da referida minorante. 8. Ordem denegada." (STF HC 111.666/MG Rel. Min. Luiz Fux j. 08.05.12 DJU 23.05.12).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA: INADMISSIBILIDADE. DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO VOLTADA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA: CIRCUNSTÂNCIAS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06 E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA: IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. [...] 6. Os fatos que deram ensejo à não aplicação da causa de diminuição de pena prevista na Lei de Tóxicos são hígidos e suficientes para atestar a dedicação do Paciente às atividades criminosas. 7. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam

situações caracterizadoras de atividades criminosas. [...] (STF HC 109.236/SP Rel. Min. Cármen Lúcia j. 13.12.11 DJU 14.23.12).

Dessa forma, torna-se definitiva a pena em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. A pena pecuniária foi fixada pelos mesmos critérios, e o valor de cada dia-multa foi estabelecido no mínimo ante a ausência de dados nos autos quanto à situação econômica do réu.

Registre-se que o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 44 da Lei 11.343/06, nas partes em que se vedava a concessão de liberdade provisória (HC n. 104.339, rel. Min. Gilmar Mendes) e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (HC n. 97.256, rel. Min. Ayres Britto), bem como do parágrafo 1º do art. 2º da Lei n. 8072/90, que impunha o regime inicial fechado (HC n 111.849, rel. Min. Dias Toffoli).

Todavia, a gravidade in concreto do delito, considerando a quantidade e diversidade das drogas, assim como o alto potencial lesivo da cocaína e do crack para saúde pública, indica um grau acentuado de culpabilidade, de forma que o regime inicial fechado mostra-se necessário para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE COMO FUNDAMENTO PARA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL E PARA A NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ORDEM DENEGADA. Possibilidade de fixar regime inicial fechado e de afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido. Precedentes. Ordem denegada.” (STF – HC 119.515/AC – Rel. Min. Cármen Lúcia – j. 03.12. – DJU 10.12.13)

Pelo mesmo motivo, não é hipótese de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, insuficiente para prevenção e reprovação da conduta.

Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na ação penal para CONDENAR o réu LEANDRO DA SILVA MORAIS, qualificado nos autos, a cumprir pena de 05 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, no unitário mínimo, por incursão no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Defiro o direito de recorrer em liberdade.

Transitada em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

Após o trânsito em julgado, determino a destruição da contraprova das drogas e do objeto apreendido, bem como decreto o perdimento do valor apreendido, em favor do Funad, eis que comprovadamente obtidos com a narcotraficância, nos termos dos arts. 63 e 72 da Lei n.º 11.343/2006.

Defiro os benefícios da justiça gratuita. Anote-se.

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella -Juiz de Direito
(assinado eletronicamente)

Maua, 03 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA